Coordenadoria de Análise de Jurisprudência
DJe nº 76 Divulgação 29/04/2010 Publicação 30/04/2010
Ementário nº 2399 - 1

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

RELATOR	:	**MINISTRO PRESIDENTE**
AGTE.(S)	:	ESTADO DE ALAGOAS
ADV.(A/S)	:	PGE-AL - MARCOS SAVALL E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	:	PGE-AL - RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE
AGDO.(A/S)	:	MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADV.(A/S)	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS

EMENTA: Suspensão de Tutela Antecipada. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. *Judicialização* do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Rituximabe (Mabthera). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do relator.

Brasília, 17 de março de 2010.

MINISTRO GILMAR MENDES
PRESIDENTE E RELATOR

STF - Seção de Composição de Acórdãos 68

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504372

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

RELATOR	:	**MINISTRO PRESIDENTE**
AGTE.(S)	:	ESTADO DE ALAGOAS
ADV.(A/S)	:	PGE-AL - MARCOS SAVALL E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	:	PGE-AL - RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE
AGDO.(A/S)	:	MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADV.(A/S)	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS

R E L A T Ó R I O

O **SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES** - (Relator): Trata-se de agravo regimental, interposto pelo Estado de Alagoas, contra a decisão de fls. 59-81, em que indeferi o pedido de suspensão de tutela antecipada recursal formulado pelo agravante para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Maceió, mantida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo n.º 001.08.082235-6, que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento RITUXIMABE (MABTHERA) 500mg e RITUXIMABE (MABTHERA) 100 mg em favor da autora, visando ao tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.

Transcrevo a decisão agravada (fls. 59-81):

> **DECISÃO:** Trata-se de pedido de suspensão da antecipação da tutela recursal, ajuizado pelo Estado de Alagoas, contra decisão do Juízo de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de Maceió, mantida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, que determinou ao Estado de Alagoas o fornecimento do medicamento denominado MABTHERA (Rituximabe) em favor de MARIA DE LOURDES DA SILVA.
>
> Na origem, MARIA DE LOURDES DA SILVA ajuizou ação cominatória (fls. 20-24), com pedido de tutela antecipada, contra o Estado de Alagoas, com o fim de obter da Secretaria de Saúde Estadual o fornecimento gratuito do medicamento MABTHERA (Rituximabe), nas dosagens 500mg e 100mg, por ser portadora de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C91.1) e não dispor de condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, orçado em R$ 162.707,16 (12 frascos de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

Mabthera 500Mg no total de R$ 90.332,04 e 24 frascos de Mabthera 100Mg no total de R$ 72.375,12).

O Juízo da 17ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deferiu a antecipação de tutela vindicada (fls. 25-30).

O Estado de Alagoas pediu ao Presidente do Tribunal de Justiça a suspensão dos efeitos da antecipação de tutela deferida, sob o argumento de que o medicamento não consta da Portaria nº 5.277 do Ministério da Saúde, sendo o seu fornecimento responsabilidade do Município de Maceió (fls. 11-18).

O pedido de suspensão foi indeferido pelo Presidente do TJ/AL (fls. 32-35).

Contra o indeferimento monocrático do pedido de suspensão, o Estado de Alagoas interpôs agravo regimental (fls. 38-46), ao qual foi negado provimento, por unanimidade, pelo órgão Plenário do TJ/AL (fls. 48-55).

No pedido de suspensão formulado a esta Suprema Corte, o Estado de Alagoas alega, em síntese, existência de lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, porquanto a ação contempla medicamento cujo fornecimento cabe ao Município de Maceió, pois não está previsto na Portaria nº 2.577 do Ministério da Saúde. Alega, ainda, que o fornecimento de medicamentos não estabelecidos no âmbito de sua atribuição pela Lei nº 8.080/1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, afeta a programação estatal, acarretando despesas excessivas, o que compromete a qualidade dos serviços de saúde pública prestados pelo Estado.

Decido.

(...)

Dos documentos acostados aos autos, ressalto os seguintes dados fáticos como imprescindíveis para a análise do pleito:

a) "a requerente é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica - CID C91.1, conforme se vê do relatório médico firmado pela Dra. Ana Lúcia Rego de Oliveira Barros, CRM-AL n.º 2697" (fl. 20);

b) **conforme receituário médico, necessita urgentemente do tratamento quimioterápico de doze ciclos (infusão de 05 horas a cada 60 dias) com os medicamentos Mabthera 500Mg (12 frascos) e Mabthera 100Mg (24 frascos)** (fls. 20-21);

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

c) a requerente alega não ter condições de arcar com o **alto custo do tratamento, orçado em R$ 162.707,16** (fl. 21).

O argumento central apontado pelo Estado de Alagoas reside na ausência de obrigação legal para que o Estado forneça o serviço requerido. Sustenta caber ao Município de Maceió a prestação de saúde requerida.

(...)

Em consulta ao sítio da ANVISA na internet, é possível verificar que o medicamento Mabthera (princípio ativo Rixuximabe), produzido pela empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A., foi registrado em 7.2.2001 (registro 101000548, válido até 06/2013).

A decisão objeto do pedido de suspensão, ao determinar o fornecimento do medicamento Mabhtera, decidiu pelo fornecimento de medicamento de alto custo que não consta dos protocolos do SUS.

Discute-se, no caso, o direito à saúde como direito ao fornecimento de quimioterápico de alto custo para o tratamento de neoplasia (leucemia linfocítica crônica).

A Portaria n.° 3916, de 30 de outubro de 1998, dispõe sobre a Política Nacional de Medicamentos, estabelecendo diretrizes para a instituição de relação de medicamentos essenciais (RENAME), a regulamentação sanitária de medicamentos, a reorientação da assistência farmacêutica, a promoção da pesquisa e da produção de medicamentos, entre outras.

A assistência farmacêutica (Resolução n.° 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde), uma dentre as várias prestações de saúde que compõem o sistema brasileiro, abrange políticas econômicas que visam reduzir os preços dos medicamentos (programas como "Farmácia Popular", "Medicamento Genérico" e "Uso Racional de Medicamentos") e políticas sociais que garantam o fornecimento gratuito de medicamentos à população por meio de três programas básicos ("Medicamentos básicos", "Medicamentos estratégicos" e "Medicamentos excepcionais").

A Portaria n.° 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, instituiu a Política Nacional de Atenção Oncológica, traçando diretrizes para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos a serem implantadas pelos órgãos do SUS. Dentro desta Política Nacional, a Portaria

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

N.° 741/GM, 19 de dezembro de 2005, define as "unidades de assistência de alta complexidade em oncologia", os "centros de assistência de alta complexidade em oncologia" (CACON) e os "Centros de Referência de alta complexidade em oncologia", especificando os procedimentos que podem realizar e as normas para se credenciarem no Programa.

As instituições credenciadas ao Sistema Único de Saúde escolhem os fármacos necessários à quimioterapia ou aos outros procedimentos que julguem adequados para o tratamento do paciente e, posteriormente, requerem ao SUS o ressarcimento do valor gasto. A Portaria n.° 146/MS-SAS, de 12 de março de 2008, estabelece os códigos e os valores máximos por procedimento que as Instituições de alta complexidade em oncologia poderão reaver.

Na hipótese dos autos, o medicamento requerido, por ter um custo muito elevado, não se enquadra dentro dos limites de valores para tratamento quimioterápico transferidos pelo SUS para as instituições conveniadas. Em razão disso, a autora ajuizou ação ordinária buscando a condenação do Estado de Alagoas no fornecimento do medicamento Mabthera (Rituximabe).

Não vislumbro na decisão impugnada risco de grave lesão à ordem pública, uma vez considerados os seguintes dados fáticos:

- o medicamento Mabthera está registrado na ANVISA, o que atesta sua segurança para o consumo;

- consta dos autos que a paciente é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C 91.1), conforme atestado pela Médica Ana Lúcia Rego de Oliveira (CRM-AL 2697), necessitando com urgência do tratamento quimioterápico de doze ciclos consecutivos com Mabthera 500Mg e 100Mg;

- a requerente declara não possuir condições de arcar com o custo do tratamento, orçado em R$ 162.707,16 (cento e sessenta e dois mil setecentos e sete reais e dezesseis centavos) mensais;

- o alto custo do medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento, visto que a Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais e a Política Nacional de Atenção Oncológica visam contemplar justamente o acesso da população acometida por neoplasias aos tratamentos disponíveis.

O Estado de Alagoas, apesar de alegar grave lesão à economia estadual, não comprova a ocorrência da lesão, limitando-se a sustentar que o Município de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

> **Maceió é que deveria ser responsabilizado pelo fornecimento**.
>
> Assim, inocorrentes os pressupostos contidos no art. 4° da Lei nº 8.437/1992, verifico que a ausência do medicamento solicitado poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à vida da paciente.
>
> Ressalte-se, ainda, que a alegação de violação à separação dos Poderes não justifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu dever constitucional de garantia do direito à saúde (art. 196), legalmente estabelecido pelas normas que regem o Sistema Único de Saúde.
>
> (...)
>
> Portanto, o fornecimento do medicamento Mabthera (Rituximabe) à paciente portadora de Leucemia Linfocítica Crônica (CID C91.1), na hipótese dos autos, não representa lesão à ordem pública.
>
> A decisão que determinou ao Estado de Alagoas o seu fornecimento, se suspensa, poderá acarretar dano irreparável para a autora.
>
> Assim, não é possível vislumbrar grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas a ensejar a adoção da medida excepcional de suspensão de tutela antecipada.
>
> Ante o exposto, **indefiro** o pedido de suspensão.

O agravante requer a reforma dessa decisão. Sustenta que a prestação dos medicamentos pleiteados é exclusiva da União, que tem o dever legal de fornecer gratuitamente medicamentos destinados ao tratamento oncológico, conforme a Lei Federal n.° 8.080/90 e na Portaria n.° 2.577 do Ministério da Saúde. Renova os argumentos da existência de grave lesão à economia e à ordem pública e jurídica, decorrente de custeio de medicação de alto custo não inserida em sua competência (fls. 84-102).

O Ministério Público Federal, no seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, haja vista o *periculum in mora* inverso, consistente na possibilidade de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

ocorrência de danos graves e irreparáveis à saúde e à vida da paciente. Transcrevo trecho do parecer (fls. 109-116):

> É sabido que, em algumas decisões (STA n.° 91, SS n.° 3145 e SS n.° 3073), a Presidência dessa Suprema Corte, nos dois primeiros casos amparando-se inclusive no pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, deferiu pedidos de suspensão de decisões que obrigavam o poder público a arcar com tratamento de saúde individualizados, entendendo presente lesão à ordem pública, sob o fundamento essencial de que o atendimento à saúde deve ser feito de forma generalizada, buscando atender o maior número possível de pessoas.
>
> Certamente, em hipóteses como a presente, onde se contrapõem, de um lado, o direito do cidadão, individualmente considerado, à prestação de serviços ou obtenção de meios que garantam os direitos consagrados da vida e da saúde e, de outro, o dever-poder do Estado de, ao gerenciar os escassos recursos disponíveis, tornar efetivas as prestações universais de saúde, de forma a beneficiar toda a coletividade, cabe ao julgador, apreciando as particularidades de cada caso, harmonizar de modo proporcional os valores em confronto, evitando o sacrifício total de um em relação ao outro.
>
> Haverá, pois, casos em que o atendimento da postulação de determinado doente, ante as especificidades verificadas nos autos, poderá significar injustificado embaraço às prestações de saúde devidas a toda a coletividade, diante, evidentemente, do quadro de notória e permanente escassez de recursos, a recomendar a provisória suspensão dos efeitos da decisão até que se torne definitiva.
>
> Noutras hipóteses, porém, e igualmente em face das particularidades que os autos revelarem, forçoso será concluir que, a despeito da extrema limitação de recursos, não poderá o poder público eximir-se, ainda que provisoriamente, da obrigação incontestavelmente sua de tornar efetivas as prestações de saúde em favor de cidadãos considerados individualmente, sem prejuízo daquelas devidas à comunidade em geral, dando concretude aos comandos constitucionais pertinentes.
>
> Nesse contexto, perde consistência o argumento de que o Sistema Único de Saúde é regido de forma descentralizada, cabendo a cada ente da federação a realização de atribuições que não se confundem. A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

responsabilidade estatal é solidária, tendo a norma do art. 196 do texto constitucional como destinatários todos os entes políticos.(...)

Na presente hipótese, conforme consta dos autos, a autora da ação originária é portadora de leucemia linfocítica crônica, necessitando do medicamento pleiteado para a manutenção de sua vida e melhora de sua saúde. (...)

A ponderação dos valores em conflito, neste caso, portanto, leva ao indeferimento do pedido de contracautela, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde e à vida dos pacientes, parecendo indubitável, na espécie, o chamado perigo de dano inverso, a demonstrar a elevada plausibilidade da pretensão veiculada na ação originária, minando, em contrapartida, a razoabilidade da suspensão requerida.

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504378

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS
V O T O

O **SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES** - (Presidente): A decisão objeto do presente pedido de suspensão determinou o fornecimento do medicamento RITUXIMABE (MABTHERA) 500mg e RITUXIMABE (MABTHERA) 100 mg em favor de MARIA DE LOURDES DA SILVA visando ao tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.

Ao indeferir o pedido de suspensão tive por fundamental haver relatório médico comprovando o estado de saúde da autora e a necessidade urgente do tratamento quimioterápico de alto custo, bem como que o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA - o que atesta sua segurança para o consumo.

Diante da relevância da concretização do direito à saúde e da complexidade que envolve a discussão de fornecimento de tratamentos e medicamentos por parte do Poder Público, inclusive por determinação judicial, entendo necessário, inicialmente, retomar o tema sob uma perspectiva mais ampla, o que faço a partir de um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS-AgR nº 846/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, *DJ* 8.11.1996 e SS-AgR nº 1.272/RJ, Rel. Carlos Velloso, *DJ* 18.5.2001.

Passo então a analisar as questões complexas relacionadas à concretização do direito fundamental à saúde, levando em conta, para tanto, as **experiências e os dados colhidos na Audiência Pública - Saúde**, realizada neste Tribunal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

A doutrina constitucional brasileira há muito se dedica à interpretação do artigo 196 da Constituição. Teses, muitas vezes antagônicas, proliferaram-se em todas as instâncias do Poder Judiciário e na seara acadêmica. Tais teses buscam definir *se*, *como* e *em que medida* o direito constitucional à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial.

As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de proteção da norma constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da natureza prestacional desse direito e da necessidade de compatibilização do que se convencionou denominar "mínimo existencial" e "reserva do possível" (*Vorbehalt des Möglichen*).

Como tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção (*Eingriffsverbote*), expressando também um postulado de proteção (*Schutzgebote*). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de excesso (*Übermassverbot*), mas também uma proibição de proteção insuficiente (*Untermassverbot*) (Claus-Wilhelm Canaris, *Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts*, JuS, 1989, p. 161.).

Nessa dimensão objetiva, também assume relevo a perspectiva dos direitos à organização e ao procedimento (*Recht auf Organization und auf Verfahren*), que são aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, de providências estatais com vistas à criação e à conformação de órgãos e procedimentos indispensáveis à sua efetivação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Ressalto, nessa perspectiva, as contribuições de Stephen Holmes e Cass Sunstein para o reconhecimento de que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos, dando significativo relevo ao tema da "reserva do possível", especialmente ao evidenciar a "escassez dos recursos" e a necessidade de se fazerem escolhas alocativas, concluindo, a partir da perspectiva das finanças públicas, que "levar a sério os direitos significa levar a sério a escassez" (HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. *The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes*. W. W. Norton & Company: Nova Iorque, 1999).

Embora os direitos sociais, assim como os direitos e liberdades individuais, impliquem tanto direitos a prestações em sentido estrito (positivos), quanto direitos de defesa (negativos), e ambas as dimensões demandem o emprego de recursos públicos para a sua garantia, é a dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o principal argumento contrário à sua judicialização.

A dependência de recursos econômicos para a efetivação dos direitos de caráter social leva parte da doutrina a defender que as normas que consagram tais direitos assumem a feição de normas programáticas, dependentes, portanto, da formulação de políticas públicas para se tornarem exigíveis. Nesse sentido, também se defende que a intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão estatal quanto à construção satisfatória dessas políticas, violaria o princípio da separação dos Poderes e o princípio da reserva do financeiramente possível.

Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo Estado varia de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O Documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos.

Dessa forma, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Essas escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as quais pressupõem "escolhas trágicas" pautadas por critérios de macrojustiça. É dizer, a escolha da destinação de recursos para uma política e não para outra leva em consideração fatores como o número de cidadãos atingidos pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos resultados etc.

Nessa linha de análise, argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual estaria vocacionado a concretizar a justiça do caso concreto (microjustiça), muitas vezes não teria condições de, ao examinar determinada pretensão à prestação de um direito social, analisar as consequências globais da destinação de recursos públicos em benefício da parte, com invariável prejuízo para o todo (AMARAL, Gustavo. *Direito, Escassez e Escolha*. Renovar: Rio de Janeiro, 2001).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Por outro lado, defensores da atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais, em especial do direito à saúde, argumentam que tais direitos são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. Assim, ao menos o "mínimo existencial" de cada um dos direitos - exigência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana - não poderia deixar de ser objeto de apreciação judicial.

O fato é que o denominado problema da "judicialização do direito à saúde" ganhou tamanha importância teórica e prática, que envolve não apenas os operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão entre os elaboradores e os executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a área de saúde e além das possibilidades orçamentárias.

Lembro, neste ponto, a sagaz assertiva do professor Canotilho segundo a qual "paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da vaguidez, indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, em termos caricaturais, sob a designação de 'fuzzismo' ou 'metodologia fuzzy'". "Em toda a sua radicalidade - enfatiza Canotilho - a censura de fuzzysmo lançada aos juristas significa basicamente que eles não sabem do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos direitos econômicos, sociais e culturais"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

(CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologia "fuzzy" e "camaleões normativos" na problemática actual dos direitos econômicos, sociais e culturais. *In*: *Estudos sobre direitos fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 100.).

Nesse aspecto, não surpreende o fato de que a problemática dos direitos sociais tenha sido deslocada, em grande parte, para as teorias da justiça, as teorias da argumentação e as teorias econômicas do direito (CANOTILHO, *op. cit.*, p. 98).

Enfim, como enfatiza Canotilho, "havemos de convir que a problemática jurídica dos direitos sociais se encontra hoje numa posição desconfortável" (CANOTILHO, *op. cit.*, p. 99).

De toda forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve. Juízos de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de complexas relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em outros termos, entre direitos individuais e bens coletivos.

Alexy segue linha semelhante de conclusão, ao constatar a necessidade de um modelo que leve em conta todos os argumentos favoráveis e contrários aos direitos sociais, da seguinte forma:

> "Considerando os argumentos contrários e favoráveis aos direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os lados dispõem de argumentos de peso. A solução consiste em um modelo que leve em consideração tanto os argumentos a favor quantos os argumentos contrários. Esse modelo é a expressão da idéia-guia formal apresentada anteriormente, segundo a qual os direitos fundamentais da Constituição alemã são posições que, do ponto de vista do direito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

> constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar. (...) De acordo com essa fórmula, a questão acerca de quais direitos fundamentais sociais o indivíduo definitivamente tem é uma questão de sopesamento entre princípios. De um lado está, sobretudo, o princípio da liberdade fática. Do outro lado estão os princípios formais da competência decisória do legislador democraticamente legitimado e o princípio da separação de poderes, além de princípios materiais, que dizem respeito sobretudo à liberdade jurídica de terceiros, mas também a outros direitos fundamentais sociais e a interesses coletivos." (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 511-512)

Ressalte-se, não obstante, que a questão dos direitos fundamentais sociais enfrenta desafios no direito comparado que não se apresentam em nossa realidade. Isso porque a própria existência de direitos fundamentais sociais é questionada em países cujas Constituições não os preveem de maneira expressa ou não lhes atribuem eficácia plena. É o caso da Alemanha, por exemplo, cuja Constituição Federal praticamente não contém direitos fundamentais de maneira expressa (ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 500), e de Portugal, que diferenciou o regime constitucional dos direitos, liberdades e garantias do regime constitucional dos direitos sociais (ANDRADE, José Carlos Vieira de. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. 3ª Edição. Coimbra: Almedina, 2004, p. 385).

Ainda que essas questões tormentosas permitam entrever os desafios impostos ao Poder Público e à sociedade na concretização do direito à saúde, é preciso destacar de que forma a nossa Constituição estabelece os limites e as possibilidades de implementação deste direito.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como (1) "direito de todos" e (2) "dever do Estado", (3) garantido mediante "políticas sociais e econômicas (4) que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos", (5) regido pelo princípio do "acesso universal e igualitário" (6) "às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

Examinemos cada um desses elementos.

(1) direito de todos:

É possível identificar, na redação do referido artigo constitucional, tanto um direito individual quanto um direito coletivo à saúde. Dizer que a norma do artigo 196, por tratar de um direito social, consubstancia-se tão somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo poder público, significaria negar a força normativa da Constituição.

A dimensão individual do direito à saúde foi destacada pelo Ministro Celso de Mello, relator do AgR-RE n.° 271.286-8/RS, ao reconhecer o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Ressaltou o Ministro que "a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente", impondo aos entes federados um dever de prestação positiva. Concluiu que "a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF, art. 197)", legitimando a atuação do Poder Judiciário nas hipóteses em que a Administração Pública

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

descumpra o mandamento constitucional em apreço. (AgR-RE N. 271.286-8/RS, Rel. Celso de Mello, *DJ* 12.09.2000).

Não obstante, esse direito subjetivo público é assegurado mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde.

Em decisão proferida na ADPF n.° 45/DF, o Min. Celso de Mello consignou o seguinte:

> "Desnecessário acentuar-se, considerando o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausentes qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos". (ADPF-MC N.° 45, Rel. Celso de Mello, *DJ* 4.5.2004).

Assim, a garantia judicial da prestação individual de saúde, *prima facie*, estaria condicionada ao não comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, por certo, deve ser sempre demonstrado e fundamentado de forma clara e concreta, caso a caso.

(2) dever do Estado:

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196.

A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político-administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional n.° 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação.

A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3° do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2° do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90.

O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

(3) garantido mediante políticas sociais e econômicas:

A garantia mediante políticas sociais e econômicas ressalva, justamente, a necessidade de formulação de políticas públicas que concretizem o direito à saúde por meio de escolhas alocativas. É incontestável que, além da necessidade de se distribuirem recursos naturalmente escassos por meio de critérios distributivos, a própria evolução da medicina impõe um viés programático ao direito à saúde, pois sempre haverá uma nova descoberta, um novo exame, um novo prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a volta de uma doença supostamente erradicada.

(4) políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos:

Tais políticas visam à redução do risco de doença e outros agravos, de forma a evidenciar sua dimensão preventiva. As ações preventivas na área da saúde foram, inclusive, indicadas como prioritárias pelo artigo 198, inciso II, da Constituição.

(5) políticas que visem ao acesso universal e igualitário:

O constituinte estabeleceu, ainda, um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde.

Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, o art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

que alcancem a população como um todo (STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, *DJ* 26.02.2007).

O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da federação, garantindo, inclusive, a "*igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie*" (art. 7°, IV, da Lei 8.080/90).

(6) ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde:

O estudo do direito à saúde no Brasil leva a concluir que os problemas de eficácia social desse direito fundamental devem-se muito mais a questões ligadas à implementação e à manutenção das políticas públicas de saúde já existentes - o que implica também a composição dos orçamentos dos entes da federação - do que à falta de legislação específica. Em outros termos, o problema não é de inexistência, mas de execução (administrativa) das políticas públicas pelos entes federados.

A Constituição brasileira não só prevê expressamente a existência de direitos fundamentais sociais (artigo 6°), especificando seu conteúdo e forma de prestação (artigos 196, 201, 203, 205, 215, 217, entre outros), como não faz distinção entre os direitos e deveres individuais e coletivos (capítulo I do Título II) e os direitos sociais (capítulo II do Título II), ao estabelecer que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5°, § 1°, CF/88). Vê-se, pois, que os direitos fundamentais sociais foram acolhidos pela Constituição Federal de 1988 como autênticos direitos fundamentais. Não há dúvida - deixe-se claro - de que as demandas que buscam a efetivação de prestações de saúde devem

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

ser resolvidas a partir da análise de nosso contexto constitucional e de suas peculiaridades.

Mesmo diante do que dispõem a Constituição e as leis relacionadas à questão, o que se tem constatado, de fato, é a crescente controvérsia jurídica sobre a possibilidade de decisões judiciais determinarem ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos, decisões estas nas quais se discute, inclusive, os critérios considerados para tanto.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, é recorrente a tentativa do Poder Público de suspender decisões judiciais nesse sentido. Na Presidência do Tribunal existem diversos pedidos de suspensão de segurança, de suspensão de tutela antecipada e de suspensão de liminar, com vistas a suspender a execução de medidas cautelares que condenam a Fazenda Pública ao fornecimento das mais variadas prestações de saúde (fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses; criação de vagas de UTIs e leitos hospitalares; contratação de servidores de saúde; realização de cirurgias e exames; custeio de tratamento fora do domicílio, inclusive no exterior, entre outros).

Assim, levando em conta a grande quantidade de processos e a complexidade das questões neles envolvidas, convoquei **Audiência Pública para ouvir os especialistas em matéria de Saúde Pública,** especialmente os gestores públicos, os membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia da União, Estados e Municípios, além de acadêmicos e de entidades e organismos da sociedade civil.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores envolvidos, ficou constatada a necessidade de se redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da interferência judicial em âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de políticas públicas.

Esse foi um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates ocorridos na Audiência Pública-Saúde: no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes.

Esse dado pode ser importante para a **construção de um critério ou parâmetro para a decisão** em casos como este, no qual se discute, primordialmente, o problema da interferência do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes.

Assim, também com base no que ficou esclarecido na Audiência Pública, o primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte. Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente.

Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.

Não raro, busca-se, no Poder Judiciário, a condenação do Estado ao fornecimento de prestação de saúde não registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Como ficou claro nos depoimentos prestados na Audiência Pública, é vedado à Administração Pública fornecer fármaco que não possua registro na ANVISA.

A Lei Federal n.° 6.360/76, ao dispor sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, determina, em seu artigo 12, que "*nenhum dos produtos de que trata esta Lei,* ***inclusive os importados****, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde*". O artigo 16 da referida Lei estabelece os requisitos para a obtenção do registro, entre eles o de que o produto seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe. O Art. 18 ainda determina que, em se tratando de medicamento de procedência estrangeira, deverá ser comprovada a existência de registro válido no país de origem.

O registro de medicamento, como ressaltado pelo Procurador-Geral da República na Audiência Pública, é uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

garantia à saúde pública. E, como ressaltou o Diretor-Presidente da ANVISA na mesma ocasião, a Agência, por força da lei de sua criação, também realiza a regulação econômica dos fármacos. Após verificar a eficácia, a segurança e a qualidade do produto e conceder-lhe o registro, a ANVISA passa a analisar a fixação do preço definido, levando em consideração o benefício clínico e o custo do tratamento. Havendo produto assemelhado, se o novo medicamento não trouxer benefício adicional, não poderá custar mais caro do que o medicamento já existente com a mesma indicação.

Por tudo isso, o registro na ANVISA configura-se como condição necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, sendo o primeiro requisito para que o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação.

Claro que essa não é uma regra absoluta. Em casos excepcionais, a importação de medicamento não registrado poderá ser autorizada pela ANVISA. A Lei n.º 9.782/99, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite que ela dispense de "registro" medicamentos adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso de programas em saúde pública pelo Ministério da Saúde.

O segundo dado a ser considerado é a existência de motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS. Há casos em que se ajuíza ação com o objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não custear por entender que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Nessa hipótese, podem ocorrer, ainda, duas situações: 1°) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente; 2°) o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia.

A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Isso porque o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da "Medicina com base em evidências". Com isso, adotaram-se os "Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas", que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente.

Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, **podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial.

Situação diferente é a que envolve a inexistência de tratamento na rede pública. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema de Saúde brasileiro.

Os tratamentos experimentais (sem comprovação científica de sua eficácia) são realizados por laboratórios ou centros médicos de ponta, consubstanciando-se em pesquisas clínicas. A participação nesses tratamentos rege-se pelas normas que regulam a pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser condenado a fornecê-los.

Como esclarecido, na Audiência Pública da Saúde, pelo Médico Paulo Hoff, Diretor Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, essas drogas não podem ser compradas em nenhum país, porque nunca foram aprovadas ou avaliadas, e o acesso a elas deve ser disponibilizado apenas no âmbito de estudos clínicos ou programas de acesso expandido, não sendo possível obrigar o SUS a custeá-las. No entanto, é preciso que o laboratório que realiza a pesquisa continue a fornecer o tratamento aos pacientes que participaram do estudo clínico, mesmo após seu término.

Quanto aos novos tratamentos (ainda não incorporados pelo SUS), é preciso que se tenha cuidado redobrado na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

apreciação da matéria. Como frisado pelos especialistas ouvidos na Audiência Pública, o conhecimento médico não é estanque, sua evolução é muito rápida e dificilmente suscetível de acompanhamento pela burocracia administrativa.

Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a aprovação de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento há muito prestado pela iniciativa privada.

Parece certo que a inexistência de Protocolo Clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que haja instrução processual, com ampla produção de provas, o que poderá configurar-se um obstáculo à concessão de medida cautelar.

Portanto, independentemente da hipótese levada à consideração do Poder Judiciário, as premissas analisadas deixam clara a necessidade de instrução das demandas de saúde para que não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças, peças processuais que, muitas vezes, não contemplam as especificidades do caso concreto examinado, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde. Esse é mais um dado incontestável, colhido na Audiência Pública - Saúde.

Com fundamento nessas considerações, que entendo essenciais para a reflexão e a discussão do presente caso pelo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

Plenário desta Corte, retomo, de forma específica, as razões apresentadas no agravo regimental.

O agravo não merece provimento. Conforme constou da decisão agravada, o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA, o que atesta sua segurança para o uso, além disso há provas da impossibilidade de a paciente custeá-lo.

O argumento central do agravante é que medicamentos para tratamento de câncer devem ser fornecidos pela União.

Após refletir sobre as informações colhidas na Audiência Pública - Saúde, e também sobre a jurisprudência recente deste Tribunal, é possível afirmar que, em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos entes da federação deve ser efetivamente solidária.

No RE 195.192-3/RS, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal consignou o entendimento segundo o qual a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Nesse sentido, o acórdão restou assim ementado:

> "SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." (RE 195.192-3/RS, 2ª Turma, Ministro Marco Aurélio, *DJ* 22.02.2000).

Em sentido idêntico, no RE-AgR 255.627-1, o Ministro Nelson Jobim afastou a alegação do Município de Porto Alegre de que não seria responsável pelos serviços de saúde de alto custo. O Ministro Nelson Jobim, amparado no precedente do RE 280.642, no qual a 2ª Turma havia decidido questão idêntica, negou provimento ao Agravo Regimental do Município:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

> "(...) A referência, contida no preceito, a "Estado" mostra-se abrangente, a alcançar a União Federal, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios. Tanto é assim que, relativamente ao Sistema Único de Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo n.º 195, com recursos do orçamento, da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Já o caput do artigo informa, como diretriz, a descentralização das ações e serviços públicos de saúde que devem integrar rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo. Não bastasse o parâmetro constitucional de eficácia imediata, considerada a natureza, em si, da atividade, afigura-se como fato incontroverso, porquanto registrada, no acórdão recorrido, a existência de lei no sentido da obrigatoriedade de fornecer-se os medicamentos excepcionais, como são os concernentes à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), às pessoas carentes. O município de Porto Alegre surge com responsabilidade prevista em diplomas específicos, ou seja, os convênios celebrados no sentido da implantação do Sistema Único de Saúde, devendo receber, para tanto, verbas do Estado. Por outro lado, como bem assinalado no acórdão, a falta de regulamentação municipal para o custeio da distribuição não impede fique assentada a responsabilidade do Município. (...)" (RE-AgR 255.627-1/RS, 2ª Turma, Ministro Nelson Jobim, *DJ* 21.11.2000)

A responsabilidade dos entes da federação foi muito enfatizada durante os debates na Audiência Pública - Saúde, oportunidade em que externei os seguintes entendimentos sobre o tema:

> O Poder Judiciário, acompanhado pela doutrina majoritária, tem entendido que a competência comum dos entes resulta na sua responsabilidade solidária para responder pelas demandas de saúde.
>
> Muitos dos pedidos de suspensão de tutela antecipada, suspensão de segurança e suspensão de liminar fundamentam a ocorrência de lesão à ordem pública na desconsideração, pela decisão judicial, dessa divisão de responsabilidades estabelecidas pela legislação do SUS, alegando que a ação deveria ter sido proposta contra outro ente da Federação.
>
> Não temos dúvida de que o Estado brasileiro é responsável pela prestação dos serviços de saúde. Importa aqui reforçar o entendimento de que cabe à União, aos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

> Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios agirem em conjunto no cumprimento do mandamento constitucional.
>
> A Constituição incorpora o princípio da lealdade à Federação por parte da União, dos Estados e Municípios no cumprimento de suas tarefas comuns.

De toda forma, parece certo que, quanto ao desenvolvimento prático desse tipo de responsabilidade solidária, deve ser construído um modelo de cooperação e de coordenação de ações conjuntas por parte dos entes federativos.

Ressalto que o tema da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde também poderá ser apreciado pelo Tribunal no RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, o qual tem repercussão geral reconhecida, nos termos da seguinte ementa:

> SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.

Também tramita nesta Corte a Proposta de Súmula Vinculante n.° 4, que propõe tornar vinculante o entendimento jurisprudencial a respeito da responsabilidade solidária dos entes da federação no atendimento das ações de saúde. Referida PSV teve a tramitação sobrestada por decisão da Ministra Ellen Gracie, Presidente da Comissão de Jurisprudência, e está no aguardo da apreciação do mérito do referido RE 566.471 (*DJe* 26.8.09).

Diante do exposto, meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 504383

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

V O T O
(Apartes)

A Senhora Ministra Ellen Gracie - Senhor Presidente, acrescento o meu voto ao de todos os membros do Tribunal para negar provimento a esses agravos regimentais, fazendo, porém, uma ponderação que também decorre de toda a discussão que tivemos até agora.

O Ministro Marco Aurélio relembrou que, no RE 566.471, o Tribunal já reconheceu repercussão geral. E faço, desde logo, uma ponderação aos colegas: Se efetivamente será possível extrair um julgamento em repercussão geral que sirva a toda essa miríade de casos tão diversos entre si, em que as circunstância fáticas são muitas vezes únicas. Talvez, se nós cuidarmos de uma categoria geral, por exemplo os portadores de diabetes que pleiteiam os reagentes e as fitas para fazerem exames - essa seria uma categoria homogênea passível de solução idêntica. Porém, as moléstias que são trazidas ao Judiciário, e os medicamentos requisitados são os mais variados possível. Faço, portanto, essa indagação ao Tribunal: Seria efetivamente viável darmos repercussão geral a essa matéria?

O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente e Relator) - No caso do Ministro Marco Aurélio, pelo que percebi, inclusive li a ementa da repercussão geral, o recurso foca exatamente a questão da responsabilidade solidária.

O Senhor Ministro Marco Aurélio - Exato.

Presidente, o recurso extraordinário tem balizas próprias. E decidiremos, consideradas essas balizas, o conflito de interesses envolvido. Agora, já decidimos quanto à repercussão e a

admitimos. Não cabe ao Tribunal rever o que assentado, mas, sim, julgar o recurso extraordinário.

A Senhora Ministra Ellen Gracie - Eu, sinceramente, continuo colocando aos colegas essa dúvida, essa indagação, essa perplexidade diante de um sistema novo que estamos inaugurando, o da repercussão geral. Se acaso, não nessa hipótese específica, chegássemos à conclusão, em um outro caso, de que não há repercussão geral, essa decisão poderá ser revista?

O Senhor Ministro Marco Aurélio - Fique tranqüila, Ministra, a decisão não será polivalente.

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário.

O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de proteção ao direito à saúde, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público, ainda mais se se tiver presente que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser (necessariamente) implementado mediante adoção de políticas públicas conseqüentes e responsáveis.

Ao julgar a ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, proferi decisão assim ementada (Informativo/STF nº 345/2004):

"ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL

*DO CONTROLE **E** DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO **EM TEMA** DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, **QUANDO CONFIGURADA** HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. **DIMENSÃO POLÍTICA** DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL **ATRIBUÍDA** AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **INOPONIBILIDADE** DO ARBÍTRIO ESTATAL **À EFETIVAÇÃO** DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. **CARÁTER RELATIVO** DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. **CONSIDERAÇÕES** EM TORNO DA CLÁUSULA **DA 'RESERVA DO POSSÍVEL'. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO**, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, **DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE** DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR **DO 'MÍNIMO EXISTENCIAL'. VIABILIDADE INSTRUMENTAL** DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO **NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO** DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE **SEGUNDA** GERAÇÃO)."*

Salientei, então, **em referida decisão**, que o Supremo Tribunal Federal, **considerada a dimensão política** da jurisdição constitucional outorgada a esta Corte, **não pode demitir-se** do gravíssimo encargo **de tornar efetivos** os direitos econômicos, sociais e culturais **que se identificam** - enquanto direitos **de segunda** geração - **com** as liberdades positivas, reais **ou** concretas (**RTJ 164/158-161**, Rel. Min. CELSO DE MELLO - **RTJ 199/1219-1220**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, **v.g.**).

É que, se assim não for, **restarão comprometidas** a integridade **e** a eficácia da própria Constituição, **por efeito de violação negativa** do estatuto constitucional, **motivada** por inaceitável inércia governamental **no adimplemento** de prestações positivas **impostas** ao Poder Público, **consoante já advertiu**, em tema

de inconstitucionalidade por omissão, **por mais de uma vez** (**RTJ 175/1212-1213**, Rel. Min. CELSO DE MELLO), **o Supremo Tribunal Federal**:

> "***DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO***.
> - ***O desrespeito*** *à Constituição* ***tanto*** *pode ocorrer mediante* ***ação*** *estatal* ***quanto*** *mediante* ***inércia*** *governamental.* ***A situação de inconstitucionalidade*** *pode derivar* ***de um comportamento ativo*** *do Poder Público,* ***que age*** *ou* ***edita*** *normas* ***em desacordo*** *com o que dispõe a Constituição,* ***ofendendo-lhe***, *assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados.* ***Essa conduta estatal***, *que importa em um '****facere****' (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade* ***por ação***.
> - ***Se o Estado deixar de adotar*** *as medidas* ***necessárias à realização concreta*** *dos preceitos da Constituição,* ***em ordem*** *a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis,* ***abstendo-se***, *em conseqüência,* ***de cumprir o dever de prestação*** *que a Constituição lhe impôs,* ***incidirá em violação negativa*** *do texto constitucional. Desse '****non facere****' ou '****non praestare****', resultará a inconstitucionalidade* ***por omissão***, *que pode ser* ***total***, *quando* ***é nenhuma*** *a providência adotada,* ***ou parcial***, *quando* ***é insuficiente*** *a medida efetivada pelo Poder Público.*
> . . . . . .
> - ***A omissão*** *do Estado -* ***que deixa de cumprir***, *em maior ou em menor extensão,* ***a imposição*** *ditada pelo texto constitucional -* ***qualifica-se*** *como comportamento* ***revestido*** *da maior gravidade político-jurídica, eis que,* ***mediante inércia***, *o Poder Público* ***também desrespeita*** *a Constituição,* ***também ofende*** *direitos que nela se fundam* ***e também impede***, *por ausência de medidas concretizadoras,* ***a própria aplicabilidade*** *dos postulados e princípios da Lei Fundamental."*
> (**RTJ 185/794-796**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, **Pleno**)

É certo - tal como observei no exame **da ADPF 45/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO (**Informativo/STF** nº 345/2004) - **que não se inclui**, ordinariamente, **no âmbito** das funções institucionais do Poder Judiciário - **e** nas desta Suprema Corte, em especial - **a atribuição de formular e de implementar** políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "**Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976**", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), **pois**, nesse domínio, o encargo reside, **primariamente**, nos Poderes Legislativo **e** Executivo.

Impende assinalar, contudo, que a incumbência de fazer implementar políticas públicas **fundadas** na Constituição **poderá** atribuir-se, **ainda** que excepcionalmente, **ao Judiciário**, **se e quando** os órgãos estatais competentes, **por descumprirem** os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, **vierem a comprometer**, com tal comportamento, **a eficácia e a integridade** de direitos individuais **e/ou** coletivos **impregnados** de estatura constitucional, **como sucede** na espécie ora em exame.

Mais do que nunca, Senhor Presidente, **é preciso enfatizar** que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos

fundamentais, de índole social, **qualifica-se** como expressiva **limitação** à discricionariedade administrativa.

Isso significa que a intervenção jurisdicional, **justificada** pela ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação real ao direito à saúde, **tornar-se-á plenamente legítima** (**sem** qualquer ofensa, portanto, **ao postulado** da separação de poderes), **sempre que se impuser**, nesse processo de ponderação de interesses **e** de valores em conflito, **a necessidade** de fazer prevalecer a *decisão política fundamental* que o legislador constituinte **adotou** em tema de respeito **e** de proteção ao direito à saúde.

Cabe referir, neste ponto, **ante a extrema pertinência** de suas observações, **a advertência** de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre Procuradora Regional da República ("**Políticas Públicas - A Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público**", p. 59, 95 **e** 97, 2000, Max Limonad), **cujo magistério**, a propósito **da limitada** discricionariedade governamental **em tema de concretização** das políticas públicas constitucionais, **corretamente assinala**:

> "***Nesse contexto constitucional***, que implica também na renovação das práticas políticas, o administrador

está vinculado *às políticas públicas* ***estabelecidas*** *na Constituição Federal; a sua omissão* ***é passível*** *de responsabilização* ***e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.***

. . . . . .

Como demonstrado no item anterior, ***o administrador público está vinculado à Constituição*** *e às normas infraconstitucionais* ***para a implementação*** *das políticas públicas* ***relativas*** *à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.*

. . . . . .

Conclui-se*, portanto,* ***que o administrador não tem discricionariedade*** *para deliberar sobre a oportunidade* ***e*** *conveniência* ***de implementação*** *de políticas públicas* ***discriminadas*** *na ordem social constitucional,* ***pois tal restou deliberado pelo Constituinte*** *e pelo legislador que elaborou as normas de integração.*

. . . . . .

As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, ***cabendo ao Juiz dar sentido concreto*** *à norma* ***e controlar a legitimidade*** *do ato administrativo (omissivo ou comissivo),* ***verificando*** *se o mesmo não contraria sua finalidade constitucional, no caso,* ***a concretização*** *da ordem social constitucional."* (**grifei**)

Não deixo de conferir, no entanto, **assentadas** tais premissas, **significativo relevo** ao tema pertinente **à** "***reserva do possível***" (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "**The Cost of Rights**", 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, "**A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais**", p. 245/246, 2002, Renovar), **notadamente em sede de efetivação e implementação** (sempre onerosas) dos direitos de **segunda** geração (direitos econômicos, sociais e culturais), **cujo adimplemento**, pelo Poder Público, **impõe e exige**,

deste, prestações estatais **positivas** concretizadoras de tais prerrogativas individuais **e/ou** coletivas.

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - **além** de caracterizar-se pela **gradualidade** de seu processo de concretização - **depende**, em grande medida, de um **inescapável** vínculo financeiro **subordinado** às possibilidades orçamentárias do Estado, **de tal modo** que, **comprovada**, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, **desta não se poderá** razoavelmente exigir, então, **considerada** a limitação material referida, **a imediata efetivação** do comando fundado no texto da Carta Política.

Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, **em tal hipótese**, criar obstáculo artificial **que revele** - a partir de **indevida** manipulação de sua atividade financeira **e/ou** político-administrativa - **o ilegítimo**, **arbitrário e censurável** propósito **de** fraudar, **de** frustrar **e de** inviabilizar o estabelecimento e a preservação, **em favor da** pessoa **e dos** cidadãos, de condições materiais **mínimas** de existência (**ADPF 45/DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, **Informativo/STF** nº 345/2004).

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "*reserva do possível*" - ressalvada a ocorrência de **justo** motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, **dolosamente**, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Tratando-se de típico direito de prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, a proteção à saúde - que compreende todas as prerrogativas, individuais **ou** coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 196) - tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, **em torno** da efetiva realização de tal comando, o Poder Público **disponha** de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, **e de cujo exercício** possa resultar, paradoxalmente, com base **em simples alegação** de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial.

O caso ora em exame, Senhor Presidente, põe em evidência o altíssimo relevo jurídico-social que assume, em nosso

ordenamento positivo, **o direito à saúde**, **especialmente** em face do mandamento **inscrito no art. 196** da Constituição da República, **que assim dispõe**:

> "***Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido*** *mediante políticas sociais e econômicas* ***que visem à redução*** *do risco de doença e de outros agravos* ***e ao acesso universal e igualitário*** *às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."* (**grifei**)

Na realidade, **o cumprimento** do dever político-constitucional **consagrado** no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, **consistente na obrigação** de assegurar, **a todos**, a proteção à saúde, **representa** fator, que, **associado** a um imperativo de solidariedade social, **impõe-se** ao Poder Público, **qualquer** que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.

A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional **desautoriza o acolhimento** do pleito recursal que a instituição governamental interessada **deduziu** na presente causa.

Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida **no exercício da Presidência** do Supremo Tribunal Federal, **em contexto assemelhado** ao da presente causa (**Pet 1.246/SC**), **entre proteger a inviolabilidade** do direito à vida e à saúde - **que se qualifica** como

direito subjetivo inalienável **a todos** assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "*caput*", **e** art. 196) - **ou fazer prevalecer**, contra essa prerrogativa fundamental, **um interesse financeiro e secundário** do Estado, **entendo**, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica **impõem**, **ao julgador**, **uma só e possível opção**: aquela **que privilegia** o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.

Essa relação dilemática, que se instaura na presente causa, **conduz** os Juízes **deste** Supremo Tribunal **a proferir decisão que se projeta** no contexto **das denominadas** "*escolhas trágicas*" (GUIDO CALABRESI **e** PHILIP BOBBITT, "**Tragic Choices**", 1978, W. W. Norton & Company), **que nada mais exprimem senão** o estado de tensão dialética **entre** a necessidade estatal de tornar concretas **e** reais as ações e prestações de saúde **em favor** das pessoas, de um lado, **e** as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, **sempre** tão dramaticamente escassos, de outro.

Mas, como **precedentemente** acentuado, a missão institucional desta Suprema Corte, **como guardiã da superioridade** da Constituição da República, **impõe**, aos seus Juízes, **o compromisso de fazer prevalecer** os direitos fundamentais da pessoa, **dentre os quais**

avultam, por sua **inegável** precedência, **o direito** à vida **e o direito** à saúde.

Cumpre não perder de perspectiva, por isso mesmo, que o direito público subjetivo à saúde **representa** prerrogativa jurídica **indisponível**, assegurada **à generalidade** das pessoas **pela própria** Constituição da República. **Traduz** bem jurídico constitucionalmente tutelado, **por cuja integridade deve** velar, **de maneira responsável**, o Poder Público, **a quem incumbe formular - e implementar** - políticas sociais e econômicas **que visem a garantir**, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.

O caráter programático da regra inscrita **no art. 196** da Carta Política - que tem por destinatários **todos** os entes políticos **que compõem**, no plano institucional, **a organização federativa** do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "**Comentários à Constituição de 1988**", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - **não pode convertê-la em promessa constitucional inconseqüente**, **sob pena** de o Poder Público, **fraudando** justas expectativas nele depositadas pela coletividade, **substituir**, **de maneira ilegítima**, **o cumprimento** de **seu** impostergável dever **por um gesto irresponsável** de infidelidade governamental **ao que determina** a própria Lei Fundamental do Estado.

Nesse contexto, **incide**, sobre o Poder Público, **a gravíssima** obrigação de tornar efetivas **as ações e prestações de saúde**, **incumbindo-lhe** promover, **em favor** das pessoas **e** das comunidades, **medidas** - preventivas **e** de recuperação -, que, **fundadas** em políticas públicas **idôneas**, tenham por finalidade **viabilizar e dar concreção** ao que prescreve, **em seu art. 196**, a Constituição da República, **tal** como este Supremo Tribunal tem **reiteradamente** reconhecido:

> "***O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA***.
>
> *- **O direito público subjetivo à saúde** representa prerrogativa jurídica **indisponível** assegurada à **generalidade** das pessoas pela **própria** Constituição da República (art. 196). **Traduz** bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade **deve** velar, **de maneira responsável**, o Poder Público, **a quem incumbe** formular - **e implementar** - políticas sociais e econômicas **idôneas** que visem a **garantir**, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica **e** médico-hospitalar.*
>
> *- **O direito à saúde - além de qualificar-se** como direito fundamental **que assiste a todas as pessoas - representa** conseqüência constitucional **indissociável** do direito à vida. O Poder Público, **qualquer** que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, **não pode mostrar-se indiferente** ao problema da saúde da população, **sob pena** de incidir, ainda que por **censurável** omissão, **em grave comportamento inconstitucional**.*
>
> ***A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE***.
>
> *- **O caráter programático** da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários **todos** os entes políticos que compõem, no plano*

*institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - **não pode convertê-la** em promessa constitucional inconseqüente, **sob pena** de o Poder Público, **fraudando** justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, **de maneira ilegítima**, o cumprimento de **seu** impostergável dever, por um gesto **irresponsável** de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.*

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR.

*- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de **distribuição gratuita** de medicamentos a pessoas carentes **dá efetividade** a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, 'caput', e 196) **e representa**, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, **especialmente** daquelas que **nada têm e nada possuem**, **a não ser a consciência** de sua própria humanidade **e** de sua essencial dignidade. **Precedentes** do STF."*
(**RE 393.175-AgR/RS**, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, **uma das expressões** mais relevantes das liberdades reais ou concretas - **impõe**, ao Poder Público, **um dever de prestação positiva** que **somente** se terá por cumprido, **pelas instâncias governamentais**, **quando estas** adotarem providências destinadas a promover, **em plenitude**, **a satisfação efetiva** da determinação **ordenada** pelo texto constitucional.

É por tal razão, Senhor Presidente, **que tenho proferido** inúmeras decisões, **nesta** Suprema Corte, em plena harmonia com esse entendimento, **sempre a fazer prevalecer**, nos casos por mim julgados (**RTJ** 175/1212-1213, **v.g.**), **o direito fundamental** à vida, **de que o direito à saúde** representa um **indissociável** consectário, **como o atestam** os seguintes julgamentos **de que fui Relator**:

- **RE 556.886/ES** (adenocarcinoma de próstata)
- **AI 457.544/RS** (artrite reumatóide)
- **AI 583.067/RS** (cardiopatia isquêmica grave)
- **RE 393.175-AgR/RS** (esquizofrenia paranóide)
- **RE 198.265/RS** (fenilcetonúria)
- **AI 570.455/RS** (glaucoma crônico)
- **AI 635.475/PR** (hepatite "c")
- **AI 634.282/PR** (hiperprolactinemia)
- **RE 273.834-AgR/RS** (HIV)
- **RE 271.286-AgR/RS** (HIV)
- **RE 556.288/ES** (insuficiência coronariana)
- **AI 620.393/MG** (leucemia mielóide crônica)
- **AI 676.926/RJ** (lipoparatireoidismo)
- **AI 468.961/MG** (lúpus eritematoso sistêmico)
- **RE 568.073/RN** (melanoma com acometimento cerebral)
- **RE 523.725/ES** (migatia mitocondrial)

- **AI 547.758/RS** (neoplasia maligna cerebral)
- **AI 626.570/RS** (neoplasia maligna cerebral)
- **RE 557.548/MG** (osteomielite crônica)
- **AI 452.312/RS** (paralisia cerebral)
- **AI 645.736/RS** (processo expansivo intracraniano)
- **RE 248.304/RS** (status marmóreo)
- **AI 647.296/SC** (transplante renal)
- **RE 556.164/ES** (transplante renal)
- **RE 569.289/ES** (transplante renal)

Vê-se, desse modo, que, **mais do que a simples positivação** dos direitos sociais - **que traduz estágio necessário** ao processo de sua afirmação constitucional **e que atua como pressuposto indispensável** à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "**Poder Constituinte e Poder Popular**", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, **recai**, sobre o Estado, **inafastável vínculo institucional** consistente em conferir **real efetividade** a tais prerrogativas básicas, **em ordem** a permitir, **às pessoas**, nos casos **de injustificável inadimplemento** da obrigação estatal, **que tenham elas acesso** a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculadas **à realização**, por parte das entidades governamentais, **da tarefa** que lhes impôs a **própria** Constituição.

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o **poder** do cidadão de exigir, do Estado, **a implementação** de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Cumpre assinalar que **a essencialidade do direito à saúde** fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, **deixassem de respeitar** o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por **intolerável** omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, que o Estado não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 196, da Constituição, e que representa - como anteriormente já acentuado - **fator de limitação** da

discricionariedade político-administrativa do Poder Público, cujas opções, tratando-se de proteção à saúde, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.

Entendo, por isso mesmo, que se revela inacolhível a pretensão recursal deduzida pela entidade estatal interessada, notadamente em face da jurisprudência que se formou, no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão ora em análise.

Nem se atribua, indevidamente, ao Judiciário, no contexto em exame, uma (inexistente) intrusão em esfera reservada aos demais Poderes da República.

É que, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário (de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito), inclui-se a necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente omissão dos poderes públicos.

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais e ao adotar medidas

que objetivam restaurar a Constituição violada **pela inércia** dos Poderes do Estado, **nada mais faz** senão cumprir a sua missão institucional **e demonstrar**, com esse gesto, o respeito incondicional que tem **pela autoridade** da Lei Fundamental da República.

A colmatação de omissões inconstitucionais, **realizada** em sede jurisdicional, **notadamente** quando emanada **desta** Corte Suprema, **torna-se uma necessidade institucional**, quando os órgãos do Poder Público se omitem **ou** retardam, excessivamente, **o cumprimento** de obrigações a que estão sujeitos **por expressa determinação** do próprio estatuto constitucional, **ainda mais se se tiver presente** que o Poder Judiciário, **tratando-se** de comportamentos estatais **ofensivos** à Constituição, **não pode se reduzir** a uma posição de pura passividade.

As situações configuradoras de omissão inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial derivada **da insuficiente concretização**, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta Política - **refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-se** como uma das causas geradoras dos **processos informais de mudança da Constituição, tal como o revela** autorizado magistério doutrinário (ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, "**Processos Informais de Mudança da**

Constituição", p. 230/232, item n. 5, 1986, Max Limonad; JORGE MIRANDA, "**Manual de Direito Constitucional**", tomo II/406 e 409, 2ª ed., 1988, Coimbra Editora; J. J. GOMES CANOTILHO **e** VITAL MOREIRA, "**Fundamentos da Constituição**", p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra Editora).

O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais **traduz inaceitável gesto de desprezo** pela Constituição **e configura** comportamento que revela **um incompreensível** sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor **e** pelo alto significado **de que se reveste** a Constituição da República.

Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, **sem** a vontade de fazê-la cumprir integralmente, **ou**, então, **de apenas** executá-la **com o propósito subalterno** de torná-la aplicável **somente** nos pontos que se mostrarem **convenientes** aos desígnios dos governantes, **em detrimento** dos interesses maiores dos cidadãos.

A percepção da gravidade **e** das conseqüências lesivas **derivadas** do gesto infiel do Poder Público **que transgride**, por omissão **ou** por insatisfatória concretização, **os encargos** de que se

tornou depositário, **por efeito** de expressa determinação constitucional, **foi revelada**, entre nós, **já** no período monárquico, em lúcido magistério, por PIMENTA BUENO ("**Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império**", p. 45, **reedição** do Ministério da Justiça, 1958) **e reafirmada** por eminentes autores contemporâneos **em lições que acentuam o desvalor jurídico do comportamento estatal omissivo** (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "**Aplicabilidade das Normas Constitucionais**", p. 226, item n. 4, 3ª ed., 1998, Malheiros; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, "**Processos Informais de Mudança da Constituição**", p. 217/218, 1986, Max Limonad; PONTES DE MIRANDA, "**Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 1969**", tomo I/15-16, 2ª ed., 1970, RT, **v.g.**).

O desprestígio da Constituição - por *inércia* de órgãos meramente constituídos - **representa um dos mais graves aspectos da patologia constitucional**, pois reflete **inaceitável** desprezo, **por parte** das instituições governamentais, **da autoridade suprema** da Lei Fundamental do Estado.

Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN ("**Teoria de la Constitución**", p. 222, 1983, Ariel, Barcelona), **coloca em pauta o fenômeno da erosão da consciência constitucional**, motivado pela instauração, no âmbito do Estado, **de um preocupante processo de**

desvalorização funcional da Constituição escrita, **como já ressaltado**, pelo Supremo Tribunal Federal, **em diversos julgamentos**, **como resulta evidente** da seguinte decisão **consubstanciada** em acórdão assim ementado:

> "*(...)* ***DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA***.
>
> *- **O Poder Público** - **quando se abstém** de cumprir, total **ou** parcialmente, **o dever** de legislar, **imposto** em cláusula constitucional, de caráter mandatório - **infringe**, com esse comportamento negativo, **a própria integridade** da Lei Fundamental, **estimulando**, no âmbito do Estado, **o preocupante fenômeno** da erosão da consciência constitucional (**ADI 1.484-DF**, Rel. Min. CELSO DE MELLO).*
>
> *- **A inércia estatal em adimplir** as imposições constitucionais **traduz inaceitável gesto de desprezo** pela autoridade da Constituição **e configura**, por isso mesmo, **comportamento que deve ser evitado**. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.*
>
> ***DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE***.
>
> *- **O direito à legislação** só pode ser invocado pelo interessado, **quando também existir** - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - **a previsão do dever estatal de emanar normas legais**. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. (...)."*
>
> (**RTJ 183/818-819**, Rel. Min. CELSO DE MELLO, **Pleno**)

Em tema de implementação de políticas governamentais **previstas e determinadas** no texto constitucional, **notadamente nas áreas de educação infantil** (**RTJ** 199/1219-1220) **e de saúde pública** (**RTJ** 174/687 - **RTJ** 175/1212-1213), **a Corte Suprema brasileira tem proferido** decisões **que neutralizam** os efeitos nocivos, lesivos e perversos **resultantes** da inatividade governamental, **em situações** nas quais **a omissão** do Poder Público representava **um inaceitável insulto** a direitos básicos **assegurados pela própria** Constituição da República, **mas cujo exercício** estava sendo inviabilizado **por contumaz** (e irresponsável) **inércia** do aparelho estatal.

O Supremo Tribunal Federal, em referidos julgamentos, **colmatou** a omissão governamental **e conferiu** real efetividade a direitos essenciais, **dando-lhes** concreção **e**, desse modo, **viabilizando** o acesso das pessoas **à plena fruição** de direitos fundamentais, cuja realização prática lhes **estava sendo negada**, injustamente, **por arbitrária abstenção** do Poder Público.

Para além de todas as considerações que venho de fazer, **há**, ainda, Senhor Presidente, **um outro** parâmetro constitucional **que merece ser invocado**.

Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, **em tema de direitos fundamentais** de caráter social, **impede que sejam desconstituídas** as conquistas **já alcançadas** pelo cidadão **ou** pela formação social em que ele vive, **consoante adverte** autorizado magistério doutrinário (GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, "**Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais**", 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, "**Direito Constitucional e Teoria da Constituição**", p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, "**Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha**", p. 40, 2002, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor,; INGO W. SARLET, "**Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988**", "*in*" Revista Público, p. 99, n. 12, 2001).

Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social **traduz**, no processo de sua concretização, **verdadeira dimensão negativa** pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (**como** o direito à saúde), **impedindo**, em conseqüência, **que os níveis** de concretização dessas prerrogativas, **uma vez atingidos**, venham a ser reduzidos **ou** suprimidos, **exceto** nas hipóteses - **de todo inocorrente** na espécie - **em que políticas**

compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais.

Lapidar, sob todos os aspectos, **o magistério** de J. J. GOMES CANOTILHO, **cuja lição**, a propósito do tema, **estimula** as seguintes reflexões ("**Direito Constitucional e Teoria da Constituição**", 1998, Almedina, p. 320/321, item n. 3):

> "***O princípio da democracia económica e social aponta para a proibição de retrocesso social.***
> ***A idéia*** *aqui expressa também tem sido designada como proibição de 'contra-revolução social' ou da 'evolução reaccionária'.* ***Com isto quer dizer-se*** *que os direitos sociais e económicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação),* ***uma vez obtido*** *um determinado grau de realização,* ***passam a constituir****, simultaneamente, uma garantia institucional* ***e*** *um direito subjectivo.* ***A 'proibição de retrocesso social'*** *nada pode fazer contra as recessões e crises económicas (reversibilidade fáctica),* ***mas o principio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos*** *(ex.:* ***segurança social****, subsídio de desemprego,* ***prestações de saúde****),* ***em clara violação*** *do princípio da protecção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desta proteção de direitos prestacionais de propriedade, subjetivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente com os direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas. A violação no núcleo essencial efectivado justificará a sanção de inconstitucionalidade relativamente aniquiladoras da chamada justiça social. Assim, por ex., será inconstitucional uma lei que extinga o direito a subsídio de desemprego ou pretenda alargar*

> *desproporcionadamente o tempo de serviço necessário para a aquisição do direito à reforma (...). De qualquer modo, mesmo que se afirme sem reservas a liberdade de conformação do legislador nas leis sociais, as eventuais modificações destas leis devem observar os princípios do Estado de direito vinculativos da actividade legislativa e o núcleo essencial dos direitos sociais.* ***O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim****: o núcleo essencial dos direitos já realizado e efectivado através de medidas legislativas ('lei da segurança social', 'lei do subsídio de desemprego',* ***'lei do serviço de saúde'****) deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa 'anulação', 'revogação' ou 'aniquilação' pura a simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado."* (**grifei**)

Bem por isso, o Tribunal Constitucional português (**Acórdão** nº 39/84), **ao invocar a cláusula da proibição do retrocesso, reconheceu a inconstitucionalidade** de ato estatal **que revogara** garantias **já conquistadas em tema de saúde pública, vindo a proferir decisão assim resumida** pelo ilustre Relator da causa, Conselheiro VITAL MOREIRA, em douto voto **de que extraio o seguinte fragmento** ("**Acórdãos do Tribunal Constitucional**", vol. 3/95-131, **117-118**, 1984, Imprensa Nacional, Lisboa):

> "***Que o Estado não dê a devida realização às tarefas constitucionais****, concretas e determinadas,* ***que lhe estão cometidas, isso só poderá ser objecto de censura constitucional*** *em sede de inconstitucionalidade* ***por***

*omissão. **Mas quando desfaz o que já havia sido realizado** para cumprir essa tarefa, **e com isso atinge uma garantia** de um direito fundamental, **então a censura constitucional já se coloca** no plano da própria inconstitucionalidade **por acção**.*

__Se__ a Constituição __impõe__ ao Estado a realização de uma determinada tarefa - a criação de uma certa instituição, uma determinada alteração na ordem jurídica -, __então__, quando ela seja levada a cabo, __o resultado passa a ter a protecção directa da Constituição__. O Estado __não pode voltar atrás__, __não pode descumprir__ o que cumpriu, __não pode tornar__ a colocar-se na situação de devedor. (...) __Se o fizesse__, __incorreria em violação positiva__ (...) __da Constituição__.

. . . . . .

Em __grande__ medida, __os direitos sociais__ traduzem-se para o Estado __em obrigação de fazer__, sobretudo de criar certas instituições públicas (sistema escolar, __sistema de segurança social__, etc.). __Enquanto elas não forem criadas__, a Constituição __só pode__ fundamentar exigências para que se criem; __mas após terem sido criadas__, a Constituição passa a proteger a sua __existência__, como se já existissem à data da Constituição. As tarefas constitucionais impostas ao Estado em sede de direitos fundamentais no sentido de criar certas instituições ou serviços não o obrigam apenas a criá-los, __obrigam-no também a não aboli-los uma vez criados__.

Quer isto dizer que a partir do momento em que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou deixar de consistir apenas) numa obrigação __positiva__, para se transformar (ou passar também a ser) numa obrigação __negativa__. O Estado, que estava obrigado a __actuar__ para dar satisfação ao direito social, __passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social__.

Este enfoque dos direitos sociais faz hoje parte integrante da concepção deles a teoria constitucional, mesmo lá onde é escasso o elenco constitucional de direitos sociais e onde, portanto, eles têm de ser extraídos de cláusulas gerais, como a cláusula do 'Estado social'." (**grifei**)

Concluo o meu voto, Senhor Presidente. **E**, ao fazê-lo, **devo** observar **que a ineficiência** administrativa, **o descaso** governamental com direitos básicos da pessoa (**como** o direito à saúde), **a incapacidade** de gerir os recursos públicos, **a falta de visão** política na justa percepção, **pelo administrador**, do enorme significado social de que se reveste a proteção à saúde, **a inoperância** funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais **não podem nem devem representar obstáculos à execução**, pelo Poder Público, **da norma** inscrita **no art. 196** da Constituição da República, **que traduz e impõe**, ao Estado, um dever inafastável, **sob pena** de a *ilegitimidade* **dessa inaceitável** omissão governamental **importar** em grave vulneração a um direito fundamental **e que é**, no contexto ora examinado, **o direito à saúde**.

Sendo assim, em face das razões expostas, **e considerando**, sobretudo, Senhor Presidente, **o magnífico** voto proferido por Vossa Excelência, **nego provimento** ao recurso de agravo **interposto** pelo Estado de Alagoas.

É o meu voto.

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

VOTO

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Presidente, vou acompanhar Vossa Excelência, sem dúvida, e não posso deixar de dizer da alta qualidade do voto proferido, que certamente vai ficar marcado neste Tribunal.

A questão da implementação de políticas públicas tem sido tema de teses, artigos e revistas jurídicas em quadrinhos, pois poucas vezes se fala do tema seriamente - o mesmo ocorrendo com o tema da "separação" dos Poderes. Continuo a ser um velho "hegeliano", entendendo que o poder é uno e, quando ele se divide, ele deixa de ser poder.

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

VOTO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Presidente, também acho que o voto de Vossa Excelência vai ficar como um divisor de águas nas decisões da Corte sobre a matéria.

Vossa Excelência falou - e muito bem - não apenas da saúde como direito público subjetivo, como direito fundamental, mas também da saúde como política pública, federativamente onipresente, ou onifederativa: uma política pública obrigatória para todos os entes da Federação. Além disso, sugeriu que, no caso concreto, o problema não é do demandante das ações dos serviços de saúde, mas do Poder Público, que, muitas vezes, não entende, não sabe como acudir a essa demanda, dividindo os respectivos custos.

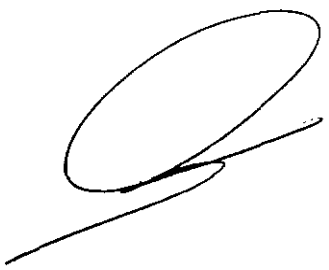
Vossa Excelência passou em revista os dispositivos da Constituição versantes sobre saúde na dupla perspectiva de política pública e de direito fundamental, mas teve o cuidado de deixar assentado em seu voto que a decisão judicial é necessariamente contextual, é empírica - aliás, a Ministra Ellen Gracie já havia dito isso em um voto anterior, magnífico, dizendo que esse é o tipo do caso que exige juízo de ponderação, atento o julgador às peculiaridades do caso. Daí Vossa Excelência trazer à tona a questão da ANVISA - e o fez com muita propriedade.

O juízo de ponderação, na linha de Dworking - que ele chama de "mandado de otimização" -, situa-se não no campo da pura racionalidade, que é uma área filosófica, mas no da razoabilidade; e a razoabilidade é necessariamente contextual ou empírica, não se expressa em juízos ou categorias mentais com pretensão de validade universal e atemporal, e, portanto, aprioristicamente.

Portanto, acho que Vossa Excelência marcou um tento, colocou muito bem a questão sob o ângulo da Constituição e, por último, habilitou devidamente o Poder Judiciário para o controle desse tipo de política pública, sem nenhuma incursão em seara alheia, e resgatou um pouco a tese da constituição dirigente, a constituição que governa quem governa, ou seja, governa permanentemente quem governa quadrienalmente.

Quero louvar o voto de Vossa Excelência e também nego provimento ao agravo e não suspendo a segurança.

***



17/03/2010 TRIBUNAL PLENO
AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, já tinha me pronunciado a respeito.

Creio que as decisões impugnadas implicaram avaliação dos valores em jogo, sobressaindo não o aspecto ligado ao Erário fiscalista, mas a necessidade daqueles que estariam a precisar de remédios e não poderiam aguardar o desfecho da ação intentada.

Por isso, acompanho Vossa Excelência, negando provimento. Já adiantei que lerei de forma mais precisa, com mais cuidado, o voto proferido por Vossa Excelência, para preparar o relatório e o voto no Recurso Extraordinário que, estou certo, já admitida a repercussão geral pela Corte, virá a julgamento. Apenas não sei quando, ante a avalanche de processos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 513152

17/03/2010 TRIBUNAL PLENO

AG.REG. NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278 ALAGOAS

EXPLICAÇÃO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Vossa Excelência, Senhor Presidente, referiu-se às opções trágicas. Trata-se de uma delicada questão que busquei discutir em meu voto.

Salientei, então, que, **entre proteger a inviolabilidade** do direito à vida **e** à saúde - **que se qualifica** como direito subjetivo inalienável **a todos** assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "*caput*", **e** art. 196) - **ou fazer prevalecer**, contra essa prerrogativa fundamental, **um interesse financeiro e secundário** do Estado, **impõe-se**, ao julgador, **uma vez configurado** esse dilema, **uma só** e possível opção: **precisamente** aquela **que privilegia**, por razões de natureza ético-jurídica, **o respeito indeclinável** à vida e à saúde humana.

Na realidade, Senhor Presidente, **tal como** pude assinalar em meu voto, **essa relação dilemática conduz** os Juízes **desta** Corte **a proferir decisão que se projeta** no contexto **das denominadas** "*escolhas trágicas*" (GUIDO CALABRESI **e** PHILIP BOBBITT, "**Tragic Choices**", 1978, W. W. Norton & Company), **que nada mais**

exprimem senão o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as ações e prestações de saúde em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de outro.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - Eu aproveito para observar que, quanto à observação do Ministro Celso de Mello, nós já tivemos casos, não nos tempos mais recentes, em que juízes decidiam, por exemplo, que alguém deveria ter o direito a uma vaga na UTI.

A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE - Os médicos são obrigados a decidir quem vai morrer, porque vão ter que tirar alguém da UTI.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE E RELATOR) - Esse tipo de decisão acabava por envolver a escolha da definição dos destinos das pessoas, porque estava a decidir se alguma pessoa deveria ser retirada da UTI, ou também a chamada fila do transplante; não é o caso do que se cuida aqui. Mas nós já tivemos casos, por exemplo, em que juízes, acolhendo pedidos do Ministério Público, determinaram que fosse construída uma UTI neonatal num

determinado local. Aí, sim, me parece que isso faz parte da concretização de políticas públicas, porque a própria legislação estabelece os critérios para a construção dessas unidades, tendo em vista elementos objetivos: número da população, número de habitantes. Então, neste caso, não parece uma interferência indevida. Portanto, nós temos que fazer essas distinções.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AG.REG.NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA 278
PROCED.: ALAGOAS
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S): ESTADO DE ALAGOAS
ADV.(A/S): PGE-AL - MARCOS SAVALL E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S): PGE-AL - RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE
AGDO.(A/S): MARIA DE LOURDES DA SILVA
ADV.(A/S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (Presidente), negou provimento ao recurso de agravo. Plenário, 17.03.2010.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Luiz Tomimatsu
Secretário